

1500763-56.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA AMEAÇA OU QUALQUER DANO GRAVE POR PARTE DE IRAMY À ESPOSA IDACI. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. BEM FUNDAMENTADA. APELANTE RESPONSÁVEL POR DESEMPENHAR E DISTRIBUIR TAREFAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 59 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500763-56.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500763-56.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185901/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18962346 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 3645/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2185901 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 3645/21/050 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN HENRIQUE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Nathan Henrique da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos art. 33 da Lei nº 11.343/06, no artigo 129, "caput", no artigo 129, §1º, e no artigo 329, "caput" e §2º, do Código Penal, todos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (cometer os crimes em ocasião de calamidade pública), e com o artigo 69, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia no dia 10 de julho de 2021, por volta das 00h, na Rua Maria Bigueti Limão, Nova Bauru, na cidade de Bauru/SP, o acusado trazia consigo e tinha em depósito, para o tráfico ilícito, 26 porções de cocaína, pesando 6,96 g (seis gramas e noventa e seis centigramas), mais 2 porções da mesma droga pesando 0,59 g (cinquenta e nove centigramas), 9 porções de 'crack', pesando 0,84 g (oitenta e quatro centigramas), e 15,28 g (quinze gramas e vinte e oito centigramas) de maconha, divididos em 11 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto, o acusado ofendeu a integridade corporal dos policiais militares Douglas Mancio de Assis Soares e Lindsey Naira de Souza, causando-lhes ferimentos. Por fim, nas mesmas condições de tempo e local indicadas, o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência à funcionário competente para executá-lo. Boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls. 23/32) e laudo definitivo (fls. 92/96).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise do auto (fls. 73/76), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 104/106, foi recebida a denúncia e determinada a notificação/citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 118), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 124).

Na decisão de fls. 135/136, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 166/168 foram ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 211/219 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base em razão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e ainda pela personalidade transviada, valorando-se, ainda, a reincidência, a agravante do "estado pandêmico", além das atenuantes da menoridade relativa e confissão. Pugnou, ainda, pelo afastamento do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o aumento de pena nos moldes do art. 129, §12 do Código Penal e a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 222/224 pleiteou, em síntese, quanto ao tráfico, a ocorrência da dirimente da coação moral irresistível, ou o reconhecimento da atenuante da confissão; em relação à lesão, que seja desclassificada para a forma culposa, já que resultante de um "esbarrão"; a absolvição no tocante à lesão da policial Lindsay, por ausência de materialidade; valoração da atenuante da menoridade relativa.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls. 23/32) e laudo definitivo (fls. 92/96).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Douglas Mancio Assis Soares e Lindsey Naara de Souza, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado entregando algo para um motociclista, em nítida atitude de venda de drogas. Afirmaram que, ao notar a presença da viatura, o motociclista fugiu, enquanto o acusado começou a caminhar, sendo abordado. Informaram que, na posse do acusado, havia saquinhos com pedras de 'crack' amarradas, alguns pinos de cocaína soltos e outros kits de cocaína, além de dinheiro. Esclareceram que a policial (Lindsey) avistou um pequeno monte de tijolos onde havia onze porções de maconha e alguns eppendorfs de cocaína. Mencionaram que o acusado tentou se desvencilhar e passou a agredir Douglas, acertando uma cotovelada, que quebrou seu antebraço esquerdo. Citaram que o acusado fugiu e Lindsey foi no encalço dele e o encontrou escondido atrás de um carro. Asseveraram que Douglas conseguiu ir até a viatura e chamar por socorro. Disseram que Lindsey e o acusado entraram em luta

corporal. Afirmaram que a policial conseguiu detê-lo e, na tentativa de algemá-lo, acabou sendo mordida no braço pelo acusado. Informaram que com o apoio de outros policiais, conseguiram conter o acusado e em seguida algemá-lo.

O policial militar Márcio Camilo da Silva Chamorro, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em síntese, que foram acionados para prestar apoio a outra equipe da polícia. Afirmou que, no local, presenciaram o policial Douglas com o braço quebrado e a policial Lindsey em luta corporal com o acusado. Informou que conseguiram detê-lo, enquanto o policial Douglas foi levado ao pronto socorro para posterior cirurgia no braço.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE POSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Nathan Henrique da Silva sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) confessou a prática do tráfico. Disse, em resumo, que, quando viu a viatura, saiu andando e foi abordado. Afirmou que possuía nove embalagens de 'crack' e uma cápsula de cocaína, além de maconha e dois kits de cocaína que estavam guardadas debaixo da lona. Informou que, quando estava sendo algemado, saiu correndo, batendo no policial, contudo, não teve a intenção de agredi-lo. Esclareceu que se escondeu, mas acabou sendo alcançado. Mencionou que mordeu a mão da policial. Citou que, quando foi colocado na viatura, chutou o veículo. Asseverou que não tentou pegar a arma do policial. Disse que, quando os demais policiais chegaram, levou chutes na cabeça e que é usuário de drogas. Afirmou que estava em liberdade há quatro meses pela prática de outro tráfico.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado confessou o delito.

E tal atenuante encontra amparo no restante da prova colhida.

Os policiais elucidaram como ocorreu a abordagem, quando surpreenderam o acusado entregando algo para um motociclista.

O acusado portava parte da droga, sendo que o restante do entorpecente foi encontrado pela policial Lindsay.

Também não é possível delinear que o acusado teria cometido o delito, sob a égide da coação moral irresistível.

Ocorre que o fato de portar drogas para um traficante (jamais caracterizado) sob ameaças, sem provocar os órgãos competentes, denota que eventual coação não seria justificável, pois, resistível.

No aspecto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA AMEAÇA OU QUALQUER DANO GRAVE POR PARTE DE IRAMY À ESPOSA IDACI. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. BEM FUNDAMENTADA. APELANTE RESPONSÁVEL POR DESEMPENHAR E DISTRIBUIR TAREFAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 59 DO CNJ. INVIÁVEL APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DE LAUDOS TOXICOLÓGICOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS COM O AGRAVANTE. CONDUTA TÍPICA POR EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE COMPROVEM O CRIME DE TRÁFICO. DOSIMETRIA. REPRIMENDA APLICADA EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O magistrado a quo fundamentou devidamente o afastamento da alegada coação moral irresistível. As comunicações existentes dão conta de que Idaci desempenhava as atividades designadas por Iramy de forma natural e espontânea, sem demonstrar qualquer situação que ensejasse em constrangimento moral. Desconstituir tal convicção demandaria o revolvimento fático-probatório do caso em análise, atraindo a aplicação do disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1662300 / RN, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2020)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Também restou delineado o crime de resistência.

Cronologicamente, e já rendido, o acusado se desvencilhou, agrediu o policial Douglas com uma cotovelada, quebrando o braço do miliciano, que teve de ser submetido à cirurgia.

Ademais, após fugir e se esconder, o acusado foi descoberto pela policial Lindsay, e, com ela manteve luta corporal, ocasião em que mordeu o braço dela.

A resistência somente foi cessada com a chegada de outros policiais, quando o acusado foi, finalmente, algemado.

Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo legal, art. 329 do Código Penal, verbis: Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

O ato legal, ou seja, a abordagem policial após a constatação do tráfico (confessado pelo acusado) foi obstada pela fuga, lutas corporais, ocultação e lesões.

Quanto às últimas (lesões), entendo que elas só restaram evidenciadas no tocante ao policial Douglas.

Como dito pelo Parquet, ele experimentou lesões graves, tanto que ficou internado por alguns dias e sofreu cirurgia (fls. 187/189).

A extensão das lesões é decorrência direta e lógica da grave agressão (cotovelada) e, por isso, não é razoável que ela tenha ocorrido sem intenção.

Importante citar que o policial Douglas ficou debilitado, e, até a data da audiência, mais de seis meses após os fatos, ainda experimentava limitação no braço lesionado.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. Insurgência defensiva contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Confissão extrajudicial. Validade, ainda que retratada em juízo, porquanto corroborada por

outros elementos de prova. Idoneidade das declarações da vítima e depoimentos dos policiais, que não revelam intenção de prejudicar injustamente o acusado. Legítima defesa não configurada. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime aberto que se afigura mais adequado às circunstâncias do caso concreto, a despeito da reincidência. Inteligência dos artigos 33, §3º, e 59, ambos do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Comarca de Bauru, Apelação Criminal nº 1509992-91.2020.8.26.0071, relator Des. Camargo Aranha Filho, julgado em 15/03/2022)

De outro lado, ainda que a prova direcione pela lesão também na policial Lindsay a materialidade não restou definida, especialmente a extensão da agressão.

Com efeito, ainda que o laudo acostado às fls. 178/179 tenha relação com Lindsay foi produzido em data anterior aos fatos (27/04/2021), e relacionado à boletim de ocorrência diverso.

Por isso, no aspecto, deve o acusado ser absolvido com escopo no art. 386, II do CPP.

Sob outro aspecto, deve o acusado Nathan permanecer custodiado.

A natureza de parte entorpecente - cocaína e 'crack' - conforme adiante se verá é perniciososa.

Ademais, o acusado é reincidente específico por tráfico de drogas (feito nº 1500734-40.2020.8.26.0594, fls. 53/54)

Além disso, o acusado agrediu dois policiais, produzindo em um deles lesões graves, prejudicando, ainda que indiretamente, o próprio serviço público.

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este cancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Tráfico de drogas

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína e crack), além da variedade (também maconha), denotam que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto porque, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico.

Contudo, confessou o delito, de modo que é possível a compensação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(STJ, 3ª Seção, REsp 1341370 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.

(...)

(STJ, 3ª Seção, HABEAS CORPUS Nº 365.963 - SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/10/2017)

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Por fim, ainda na intermediária, há a agravante da menoridade relativa, o que atenua a pena em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentas) diárias.

Com efeito, o acusado é reincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, porque o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

Resistência

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

A culpabilidade, entretanto é perniciososa.

O crime foi cometido contra dois policiais, sendo que um deles experimentou grave lesão, maculando, inclusive, o próprio serviço público.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito, atenuante que é compensada com a reincidência, como argumentado.

Também como fundamentado, incabível a agravante do estado pandêmico.

Por fim, ainda na segunda fase, a menoridade relativa atenua a reprimenda em 1/6, atingindo 2 (dois) meses de detenção.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Lesão Corporal Grave

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena permanece no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na intermediária, entendo que o acusado não confessou a lesão, visto que afirmou que "não teve a intenção".

Depois, como fundamentado, incabível a agravante do estado pandêmico.

Por fim, ainda na segunda fase, a menoridade relativa deve ser compensada com a reincidência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Descabimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas.

Seguro reconhecimento pela testemunha presencial – PARTICIPAÇÃO DE MENOR

IMPORTÂNCIA – Inocorrência. Conduta determinante para o êxito da empreitada

criminoso – Causas de aumento demonstradas pela prova oral – PENA – Possibilidade

de compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência –

Majoração pelas duas causas de aumento readequada para 3/8 – Regime inicial fechado mantido – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00028921720148260445 SP 0002892-17.2014.8.26.0445, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 24/11/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015)

Na derradeira, presente a majorante delineada no art. 129, §12 do Código Penal: § 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Com efeito, o crime foi cometido contra policial, no exercício da função, por isso, a pena é aumentada em 1/3, totalizando, em definitivo, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em razão dos bens jurídicos diversos lesados, e a mesma qualidade da reprimenda imposta (tráfico e lesão corporal grave), as penas devem ser somadas, em observância aos efeitos do concurso material de delitos, no aspecto.

Deste a pena total de reclusão é de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, além das 500 (quinhentas) diárias remanescentes do comércio espúrio.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do acusado.

Fixo o regime inicial fechado para os delitos de lesão corporal e tráfico e semiaberto para a resistência.

O réu Nathan é reincidente específico.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)
Em acréscimo, foram cometidas duas lesões (uma delas grave) provindas da resistência ao cumprimento do ato legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL para: CONDENAR o acusado NATHAN HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06 e 129, §1º, I e §12 do Código Penal.

CONDENAR o acusado NATHAN HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 329 do Código Penal.

ABSOLVER o acusado NATHAN HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pelo delito constante no art. 129, "caput" c.c. §12 do Código Penal (lesão corporal experimentada pela policial - ausência de laudo correto relativo ao fato), com fulcro no art. 386, II do CPP.

Nego ao acusado Nathan o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados. Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA